

1503607-79.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287302/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20945014 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5970/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2287302 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503607-79.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287302/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20945014 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5970/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2287302 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN JOAO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ADRIAN JOÃO GABRIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 195), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 199/201).

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2022 (fls. 204/205) e o acusado foi citado (fls. 236).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 237/238).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 237/238).

A defesa requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 241/243).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/11), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 32/37), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/126), laudo pericial (fls. 170/175) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos e aduziu que os carros estacionados em frente à sua residência eram de sua propriedade e permaneciam abertos. Os entorpecentes localizados não eram seus e desconhecesse quem seria o proprietário. Quando era menor de idade respondeu por ato infracional semelhante ao crime de tráfico e lhe foi aplicada medida socioeducativa.

Os policiais militares Caíque e Aguinaldo relataram que tinham recebido informações de que o réu armazenava entorpecentes em dois automóveis estacionados em frente à residência dele, aparentemente sem condições de circulação ante a ausência de pneus e rodas. Em patrulhamento pelo local, viram um veículo Monza e outro Passat. O Monza estava aberto e, em busca veicular, encontraram embaixo do banco do passageiro 20 porções de crack embaladas individualmente. O Passat estava trancado, porém a esposa do acusado forneceu a chave para abertura e, em seu interior, localizaram grande quantidade de entorpecente, além de tesoura e embalagens, denotando que o fracionamento era feito ali mesmo. O réu confessou que armazenava os entorpecentes para a esposa de Altair, conhecido traficante que se encontra preso, recebendo R\$ 100,00 por isso. Segundo Adrian, a mulher deixava as drogas em um terreno e o avisava, então ele coletava os entorpecentes e os guardava nos veículos até que terceiros os retirassem e levassem aos pontos de venda.

A negativa do acusado foi infirmada pelo conjunto probatório amealhado.

Os entorpecentes foram encontrados em automóveis de propriedade do réu, parados em frente à sua residência. Conforme relato dos policiais, o veículos com a maior quantidade de drogas estava trancado e a chave lhes foi entregue pela esposa do réu.

As narrativas dos policiais se mostraram coerentes e harmônicas com as demais provas e trouxeram detalhes fornecidos a eles pelo acusado, informalmente. E não foi apontado motivo crível que justificasse falsa incriminação por parte dos policiais.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem em consonância com as informações anteriormente recebidas, pela diversidade de entorpecentes, sendo o crack em porções individuais e a maconha em porção maior a ser fracionada, além de apetrechos - inclusive tesoura com resquícios de maconha (fls. 170/175) - comumente utilizados para individualização de porções para venda.

Assim, não há como acolher a tese defensiva de absolvição, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido (crack), substância altamente nociva e viciante, bem como a significativa quantidade de maconha, apesar do menor potencial desta se comparada a outras drogas. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo, de 1/5, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade e a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Restou demonstrado que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas, sendo habitualmente responsável ao menos pelo armazenamento de entorpecentes, considerando que já possuía até mesmo uma logística estabelecida para a coleta e entrega das drogas. Ademais, o próprio réu informou que lhe foi aplicada medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparável ao crime de tráfico de entorpecentes, em consonância com os documentos de fls. 51/52, explicitam que ele há muito estava envolvido com o comércio espúrio.

Considerando-se os motivos esposados na primeira e na terceira fase, a reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que,

ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças

condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado ADRIAN JOÃO GABRIEL, qualificado nos autos, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Excepcionalmente faculto ao réu o apelo em liberdade, considerando que assim permaneceu durante parte da instrução processual.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos apreendidos em favor da União.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA